



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

בעניין:

כלאתי לאה

מרח' קלאוזנר 12 הרצליה 46683
טל: 072-2511521, פקס: 072-2511520

התובעת

- נ ג ד -

1. שפרן ירון

2. שפרן שרון

ע"י ב"כ עוה"ד גד ויספלד

משד' שאול המלך 8, ת"א 64733

טל: 03-6919797, פקס: 03-6916262

הנתבעים

פסק דין

1. עניינה של התביעה, צו עשה המורה לנתבעים לסלק ידם משביל המעבר למקלט.
2. התובעת היא בעלת דירה בבית המשותף ברחוב המדרון 3, הרצליה הידוע כגוש 6520 חלקה מס' 119 (להלן: "הבית"). הנתבעים הינם בעלי דירה בבית.
3. הבית ממוקם על צלע גבעה וניצב על עמודים. לבית 3 קומות ו- 2 כניסות. בכל כניסה 3 דירות. הבית מדורג כשהמעבר ממפלס למפלס (מקומה לקומה) הוא באמצעות מדרגות. דירתה של התובעת, ממוקמת בכניסה הדרומית מזרחית של הבית בקומה הראשונה. דירתם של הנתבעים ממוקמת בכניסה הצפון מזרחית של הבית בקומה הראשונה (ראה פרוטוקול ביקור במקום מיום 25.1.12).
4. בהתאם לתשריט הבית המשותף לדירת התובעת (חלקת משנה 1) צמודה קרקע המסומנת באות א' (להלן: "קרקע א'"). לדירת הנתבעים (חלקת משנה 2) צמודה קרקע המסומנת באות ב' (להלן: "קרקע ב'"). קרקע א' וקרקע ב' משיקות אחת לשנייה. במפלס הקומה הראשונה מקלט הממוקם בסמיכות לקרקע ב'. בהתאם לתשריט הבית המשותף מסומן "שביל זכות מעבר" ("להלן: "שביל המעבר") ברוחב של 1 מ' המוביל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 142/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

מקרקע א' למקלט. בבית שני מקלטים נוספים. האחד במפלס מעל המקלט נשוא ההליך והאחר במפלס מתחת למקלט נשוא ההליך.

טענות התובעת בתמצית

5. התובעת ובני משפחתה התגוררו בדירה בשנים 1982 - 1994. לבקשת בעליה הקודמים של דירת הנתבעים נבנה קיר החוצץ בין קרקע א' ל - קרקע ב'. קיר זה הותיר פתח ברוחב של 1 מטר אשר שימש כשביל המעבר למקלט. פתח זה נסגר בדלת ע"י בעליה הקודמים של הדירה. דלת זו הייתה ניתנת לפתיחה או לנעילה לפי הצורך (להלן: "הדלת"), כך שניתן היה להגיע מקרקע א למקלט בכל עת.

6. בשנים שבין 1994 - 2011 הושכרה דירת התובעת לצדדים שלישיים. בשנת 2011 ביקשה התובעת לחזור להתגורר בדירה או אז התברר לה כי על חור מנעול הדלת הודבק דיקט, והידית הקיימת על הדלת אינה מאפשרת את פתיחתה. כן הסתבר לה כי הנתבעים בנו על חלק מקרקע ב' חדר כך ששביל המעבר והמקלט "נבלעו" בתוך החדר, והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

7. מבירור שערכה התובעת במחלקת הפיקוח של עיריית הרצליה נמצא כי החדר נעדר היתר בניה. הנתבעת 2 הודיעה לתובעת כי תאפשר לה להיכנס למקלט בכל פעם שתבקש, ואולם התובעת איננה מוכנה להיות תלויה ברצונם הטוב ובהסכמתם של הנתבעים לשם קבלת גישה לשביל ולמקלט.

8. משכך, דרשה התובעת להשיב המצב לקדמותו, כפי המופיע בתשריט הבית המשותף, ולאפשר לה מעבר חופשי למקלט בכל עת.

טענות הנתבעים בתמצית

9. בבית קיימת הסכמה בין בעלי הדירות בבית לגבי אופן השימוש שנעשה במקלטים, כך שלכל שני בעלי דירות יש זכות שימוש במקלט אחד, ובהתאמה לבעלי הדירות בקומה הראשונה, התובעת והנתבעים, יש זכות שימוש במקלט הממוקם בקומה הראשונה.

10. במועד בו רכשו הנתבעים את דירתם, 1997, היה קיים הקיר החוצץ בין קרקע א' לבין קרקע ב', וכן הייתה קיימת גם הדלת עם מנגנון נעילה. בין הנתבעים ובעלה המנוח של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 142/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

התובעת (להלן: "המנוח") הוסכם כי הדלת תיוותר נעולה ובכל עת שיידרש מעבר למקלט יתאפשר הדבר בתיאום עם הנתבעים מראש. מצב זה נוהג במשך שנים רבות, ואין התובעת יכולה כיום לשנות את היוצרות.

11. לא ניתן להשאיר הדלת פתוחה בכל עת שכן אז יתאפשר לכל בר בי רב להיכנס לשטחם, ובכך תיפגע פרטיותם. כן טענו הנתבעים שהם רשאים לנהוג בקרקע הצמודה לדירתם מנהג בעלים ואינם נזקקים לכל רשות מצד התובעת ביחס לאופן השימוש ברכושם.

12. התובעת והמנוח לא התגוררו בדירה במשך שנים רבות, ומטעם זה סירבו בכל תוקף לשפץ המקלט ולהשתתף בהוצאות אחזקתו השוטפת.

13. זכות המעבר של התובעת למקלט לא נפגעה כלל והיא רשאית לעשות שימוש בזכות זו בתיאום מראש עם הנתבעים, ובכל מקרה עליה לעשות שימוש בזכות זו בסבירות ובהגינות.

דיון והכרעה

14. על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מן העובדות ערכתי ביקור במקום ביום 25.1.12. אצטט להלן את עיקרי הפרוטוקול שנערך לאחר הביקור במקום המתארים את המצב כפי שהוא שבשטח:

"מתוך דירת הנתבעים קיימת יציאה לשטח קרקע המהווה חלק בלתי נפרד מדירת הנתבעים (קרקע ב' הוספה שלי א.ש.). בהמשכו של שטח הקרקע נצפה חדר התחום בקירות ובדלת. בתוך החדר ניתן להבחין בריצוף מפרקט, ספה, שולחן עבודה, מחשב מזגן ותאורה. בצדו הצפון מזרחי של החדר ניתן היה להבחין במקלט, נשוא המחלוקת. בפתח הכניסה למקלט נצפו מספר פריטים לאחסון כגון מדפים וכד'. בצדו הדרום מערבי של החדר ניתן היה להבחין בדלת נוספת ללא מנעול. מעבר בדלת מוביל לחצר דירתה של התובעת (קרקע א הוספה שלי א.ש.). בחצר דירת התובעת ניתן להבחין בקיר החוצץ בין שטח חצרה של התובעת לבין חצר וחדר הנתבעים לעיל. המשכו של הקיר הוא הדלת שנצפתה ללא מנעול".

15. מביקורי במקום התרשמתי, כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי בשביל המעבר, כך שהוא הפך לחלק בלתי נפרד מהחדר הבנוי על חלק מקרקע ב' הצמוד לדירתם, וכי המעבר למקלט חייב להיעשות דרך החדר הנ"ל. עוד התרשמתי כי גם המקלט נבלע הלכה למעשה בתוך החדר והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

16. סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מגדיר, בין היתר, מהו "רכוש משותף". על פי ההגדרה כל מה שאינו רשום כדירה הוא בגדר רכוש משותף: **"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות.... המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם..."**. בהתאם לתשריט הבית המשותף שביל המעבר אינו מוצמד לאף אחת מדירות הבית וגם אינו מהווה חלק מדירות הבית. משכך יש לראות את שביל המעבר כרכוש משותף של הבית.

17. שימושים הייחודי של הנתבעים בשביל המעבר המהווה כאמור רכוש משותף, כמוהו כ"הצמדה בפועל" של שביל הגישה לדירתם, ואין לראות בשימוש זה שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף שאינו דורש את הסכמת יתר בעלי הדירות בבית. ראה לעניין זה רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק-על (2)87, 732, י ויסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף (תשנ"ז – 1997), עמ' 454-455. לצורך הסכמה כזו, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית, כאמור בסעיף 62 סיפא לחוק המקרקעין.

18. על מהות ההסכמה הדרושה ע"פ החוק ומשמעותה נתן בהמ"ש את דעתו במספר פסקי דין. ראה למשל ע"א 136/63, לוויני הים ואח' נ' שורצמן ואח', פ"ד י"ז 1726 נקבע:

"... זכות השייכת לכמה שותפים ואינה מתייחסת לעניין שימושי רגיל שכולם נהנים ממנו בדרך של שיגרה, אין אחד השותפים יכול ליטול אותה או חלק ממנה לעצמו ולהדיר את השותפים האחרים ממנה שלא בהסכמתם".

ראה גם ע"א 188/76, רוזנוקס נ' הוטרר ואח', פד"י ל"א (1), 382 בע"מ 384, כן ע"א 815/81, כליפא ואח' נ' שאל ואח', פ"ד ל"ו (3), 78 בע"מ 83.

19. טענת הנתבעים ולפיה קיימת בבית הסכמה בין בעלי הדירות בדבר השימוש שנעשה במקלטים, כך שלכל שני בעלי דירות יש זכות שימוש במקלט אחד, לא הוכחה (ראה עדותו של מר אורן לוי, בעל דירה בקומה השנייה בבית, שלא ידע להשיב באיזה מקלט עושה שימוש בעל דירה בקומה השלישית של הבית. פרוטוקול מיום 30.1.12, עמ' 11, שורות 3-1, ולא הובאה כל ראיה או עדות אחרת התומכת בטענה זו). מכל מקום, אפילו הייתה מוכחת אזי תוצאתה הייתה שהמקלט בקומה הראשונה, בה מצויות דירת התובעת והנתבעים היה משרת את שתי דירות אלו בלבד. אין בעובדה זו כדי להוות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הצדק כלשהו לכך שהנתבעים סיפחו לעצמם את שביל המעבר למקלט ואת המקלט ו"בלעו" אותם בתוך החדר שבנו.

20. טענת הנתבעים כי ניתנה הסכמתו של בעלה של התובעת להצמדת שביל הגישה לדירת הנתבעים לא הוכחה בפני :

הנתבעת מס' 2 העידה כי עד למועד הגשת התביעה לא ידעה כלל כי שביל המעבר אינו חלק מדירתה, וכי רק עדכנה את המנוח בדבר בניית החדר, מאחר וסברה כי המקלט משותף לשתי הדירות. ברי כי אדם הסובר לתומו כי שטח השביל שייך לו לא יקדים בקשה להסכמה מהצד האחר, ולכן הסתפקה בעדונו של המנוח. ראה פרוטוקול מיום 30.1.12, עמ' 13, שורות 2-5 :

"עד מועד הגשת התביעה אני לא ידעתי שמדובר במטר שלא שייך לי. אני ידעתי שיש שם דלת שמטרתה מעבר למקלט. כשסגרתי את החדר לפני כ- 6.5 שנים בוודאי שעדכנתי את המנוח (בעלה של התובעת. א.ש.) גם דיברתי אתו על זה. אני גם חושבת שהוא ביקר במקום".

עדות זו גם תואמת את עדותו של נתבע 2, שהוסיף כי קיבל הסכמתו של המנוח לבניית החדר (ראה פרוטוקול מיום 30.1.12, עמ' 14, שורות 15, 24-22). פרט לעדותו זו של נתבע מס' 1 לא הובאה כל ראיה ו/או עדות בדבר הסכמת המנוח הנתבעת. עדותו זו של הנתבע 1 היא עדות יחידה של בעל דין במשפט אזרחי, שאינה זוכה לחיזוק, ולא מצאתי להסתמך עליה בלבד לצורך הוכחת ההסכמה הנתבעת (ראה סעיף 54 לפקודת הראיות {נוסח חדש}, תשל"א – 1971).

21. כך גם לא הוכח בפני כי ניתנה הסכמת שאר בעלי הדירות לבניית החדר על שביל הגישה. כל שהעיד נתבע מס' 1 לעניין זה הוא כי עדכן את בעלי הדירות בדבר בניית החדר בעל פה, ואלה לא הביעו התנגדות (פרוטוקול מיום 30.1.12, עמ' 14, שורות 25-28), ובכך אין די.

22. נראה כי הנתבעים מבקשים ללמוד על הסכמתם של בעלי הדירות בבית ובכלל זה הסכמת המנוח להצמדת שביל המעבר מתוך שתיתקם של בעלי הדירות במשך השנים (כ- 7 שנים מאז נבנה החדר. ראה עדותה של נתבעת 2, פרוטוקול מיום 30.1.12, עמ' 12, שורות 28-29 ועדותו של נתבע 1, עמ' 14, שורה 24 אשר לא נסתרו). טענה דומה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 142/11

בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה

הועלתה בת.א. (ת"א) 2816/03, **ציפורה קונצ'יצקי נ' דליה שפלן** (פורסם ב"דטה חוק ומשפט"), ונדחתה ע"י בית המשפט המחוזי אשר קבע כדלקמן:

"...כפי שכותב המלומד ח. דגן בספרו קניין על פרשת דרכים (תשס"ה – 2005) המגמה העיקרית של הדין הישראלי ביחס לשימוש ברכוש המשותף היא כינונו של משטר משפטי של זכויות ברורות. בכך הוא נבדל מן הדוקטרינה המסדירה את המוסד הקנייני של שיתוף בנכסים, המתאפיינת בחתירתה לקדם ולהשריש שיתוף פעולה דינמי. מגמה זו מחייבת קביעת כללים נוקשים ביחס לסמכות ולגרוע מזכות החזקה ברכוש המשותף (שם, בע"מ 395-396). על החשש מפני התרת הרצועה והצורך להגן מפני פגיעה ברכוש המשותף עומד אף השופט גולדברג בע"א 93/81 אליאס נ' שיפר, פ"ד לז(2) 444, שנסב סביב השאלה האם מושתק דייר שפגע בעצמו ברכוש המשותף מלטעון כנגד פגיעה שפגע אחר: "אם תותר הרצועה ובית המשפט ייתן גושפנקא לפגיעות ברכוש המשותף שאינן אפסיות עד שכל בר דעת יראה בהן דבר של מה בכך, עלול הדבר לגרום להתמוטטותו של מוסד הבתים המשותפים, שיסודותיו מורכבים ומפותלים בלאו הכי, עד שאיש הישר בעיניו יעשה ברכוש, שהוא נחלת הדיירים כולם".

23. מן המקובץ עולה כי לא מצאתי לקבל את טענת הנתבעים כי הוכחה הסכמתו של המנוח ושל שאר בעלי הדירות בבית לשימוש הייחודי האמור. ועדיין אפילו הייתה מוכחת הסכמה לא היה בכך כדי למנוע מהתובעת לדרוש את סילוק ידם של הנתבעים משביל המעבר, ואפרש:

24. הפסיקה מבחינה בין רישיון שניתן בתמורה לבין רישיון שלא ניתן בתמורה כאשר נקבע כי כאשר לא ניתנה תמורה מדובר ברישיון אשר ניתן לביטול בכל עת עם גילוי דעתו של המקנה שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון. ראה לעניין זה ע"א 618/05, גדליהו דיאמנשטיין נ' מדינת ישראל, (פורסם בתקדין) והפסיקה המוזכרת שם, וכן פרופ' נ. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24, 57:

"רשות שנלמדת מכללא אינה מונעת את בעל המקרקעין מלהביא לסיומה בכל עת על ידי גילוי דעתו כלפי פלוני שאין הוא מוכן עוד להמשיכה. זו היא רשות חנם המתחדשת מרגע לרגע, כל עוד לא פעל בעל המקרקעין לסילוקו של פלוני".

25. לא נטען וממילא לא הוכח כי הנתבעים נתנו תמורה בעד הצמדת שביל הגישה. משכך, גם בהנחה המיטיבה עם הנתבעים ששתיקת בעלי הדירות מהווה מתן הרשאה להצמדת שביל הגישה הרי שניתן לראות, לכל היותר, את השימוש שנעשה כ - "רישיון במקרקעין" ללא תמורה הניתן לביטול בכל עת. במקרה דנן, בוטל הרישיון שניתן לנתבעים, עת פנתה התובעת אליהם במכתבה מיום 21.8.11 (צורף כנספח לכתב



**מדינת ישראל
משרד המשפטים**

מס' התיק: 142/11

**בפני המפקחת על רישום מקרקעין
בנתניה**

התביעה) וביקשה: "להחזיר את מצב שביל הגישה למקלט לקדמותו, על מנת שיתאפשר מעבר חופשי בכל עת".

26. למעלה מהדרוש אציין כי עם בניית החדר לא רק ששביל המעבר למקלט מהווה חלק בלתי נפרד מהחדר, אלא שגם המקלט עצמו נבלע בתוך החדר ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. המשמעות היא שאף המקלט הוצמד בפועל לדירה, וזאת בניגוד לגמור לסעיף 55(ג) האוסר, בין היתר, הצמדת מקלט לדירה.

27. אשר על כן ונוכח כל האמור לעיל, אני מקבלת התביעה ומורה לנתבעים לפנות את שביל המעבר מכל חפץ השייך להם, ולהותיר מעבר כפי המצוין בתשריט הבית המשותף למקלט, וזאת בתוך 60 ימים מהיום.

28. על אף האמור, מאחר ומהראיות שהובאו בפני שוכנעתי כי הדלת המובילה לשביל הגישה דרך קרקע א' נבנתה עוד טרם רכשו הנתבעים את דירתם ובהסכמת התובעת והמנוח, לא מצאתי לשנות מצב זה. בעת ביקורי במקום נוכחתי כי אין לדלת מנעול. ככל ומי מהצדדים יבקש להתקין מנעול, יעשה הדבר על חשבונו לרבות שכפול המפתח שיופקד בידי התובעת.

29. בהינתן כי הנתבעים עשו שימוש ייחודי בשביל הגישה כ – 7 שנים ללא התנגדות מצד התובעת, לא מצאתי לחייב הנתבעים בהוצאות ההליך.

ניתן בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, ה' באלול תשע"ב, 23 באוגוסט 2012.

אסתי שחל
מפקחת על רישום מקרקעין
נתניה